

1500270-18.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública" (TJRS - AC - 687055624 - Rel. Alberto de Moraes Lacerda - RJTJRS 130/154).

PENA - Agravantes - Tráfico de entorpecentes - Associação - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500270-18.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500270-18.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2040999/2022 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 22984362 -

DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 2040999 - DEL.POL.BIRIGUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TONI RICO SILVA JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº 1500270-18.2022.8.26.0603 (Controle nº 373/2022)

VISTOS.

TONI RICO SILVA JUNIOR, qualificado nos autos, foi preso em flagrante delito, denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 12 de fevereiro de 2022, por volta das 23h30, à Rua Pedro

Cavalo, nº 584, Bairro Portal da Pérola II, nesta cidade e Comarca de Birigui, trazia consigo e guardava em sua residência, com o fim de tráfico, 830,99 gramas (oitocentos e trinta gramas e noventa e nove centigramas) de maconha, fracionados em três porções, e 47,20 gramas (quarenta e sete gramas e vinte centigramas) de crack, fracionados em quatro porções, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudos de constatação prévia de fls. 34, 35 e exames toxicológicos de fls. 105/107 e 113/115.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado para apresentar defesa escrita (fl. 161), cuja peça foi juntada às fls. 146/158, sobrevindo o recebimento da denúncia em 24 de maio de 2022 (fls. 189/191) e a citação do acusado à fl. 216.

Na instrução, foram colhidos os depoimentos de 02 (duas) testemunhas arroladas em comum e 04 (quatro) testemunhas arroladas pela defesa, sobrevindo, ao final, o interrogatório do réu (fls. 236/237).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (fls. 333/337).

A defesa, por sua vez, requer a absolvição do acusado, alegando coação moral irresistível. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Em caso de condenação, requereu a aplicação do artigo 33 § 4ª da Lei 11.343/2006; com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; fixação do regime aberto; a restituição dos aparelhos celulares e a quantia em espécie apreendida; e o direito do réu recorrer em liberdade (fls. 256/269).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06).

A ação penal é procedente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 03); o recibo de entrega de preso (fls. 04/05); o boletim de ocorrência (fls. 15/18); a nota de culpa (fl. 09); o depósito judicial (fl. 104); o relatório final (fls. 116/118); os laudos de constatação prévia (fls. 34/35); os laudos periciais (fls. 105/107 e 113/115); os depoimentos das testemunhas; e a confissão apresentada pelo acusado em juízo.

Na delegacia, o acusado disse que estava no interior de sua residência, momento em que chegaram os policiais militares, entraram em seu imóvel, e alegaram que encontraram substâncias entorpecentes. Negou que as substâncias sejam de sua propriedade (fl. 07).

Em juízo, o acusado confessou, disse que com ele havia apenas 01 cigarro de maconha e 01 cigarro de "mescado", para consumo próprio. Disse aos policiais que dentro da residência havia mais um tijolo de maconha e 04 porções de crack, sendo que o crack era para seu consumo e que o tijolo de maconha estava guardando para terceiro, para pagar dívidas de drogas. Afirmou que foi ameaçado para guardar a droga. Disse que um dos celulares apreendido era de seu irmão e o dinheiro era proveniente de pensão alimentícia de sua companheira (fls. 236/237).

A confissão livre e espontânea prestada no processo, serve como importante elemento de convicção para evidenciar a autoria e amparar a condenação, quando encontrar sustentação nos demais elementos de convicção produzidos.

De fato, no caso, a confissão do réu encontrou total respaldo nas demais provas carreadas aos autos.

Com efeito, as testemunhas Alecio Gaiarin e Alekssander Xavier Conrado, policiais militares, ouvidas em ambas as fases da persecução penal, relataram que receberam informações de que o acusado seria integrante do "PCC" e que estaria armado e comercializando drogas em sua residência, motivo pelo qual o abordaram. Com o

acusado foram encontrados dois cigarros de maconha, além de R\$20,00 (vinte reais). Indagado se havia mais drogas, o acusado disse que tinha maconha na área dos fundos, onde foi localizado um tijolo de maconha e quatro porções de crack. Foram apreendidos ainda, dois celulares e R\$300,00 (trezentos reais). O acusado afirmou que sua companheira não tinha conhecimento daquelas drogas (fls. 04/05, 06 e 236/237).

Os policiais confirmaram que localizaram quantidade considerável de entorpecentes e que o réu confessou que estava guardando os entorpecentes para terceiro.

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Tais depoimentos somente não terá valor quando se evidenciar o interesse dos servidores na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Importante salientar que não existe qualquer circunstância que justificasse o interesse dos policiais em prejudicar o acusado, ou em imputar falsamente a ele a prática de conduta definida como crime, sobretudo porque ele não apontou nada que justificasse essa circunstância.

A testemunha Lorrayne de Jesus Dantas, companheira do acusado, ouvida em juízo, disse que tinha conhecimento que o acusado era usuário de drogas, mas não comercializava entorpecentes. Após os fatos, o acusado lhe disse que estava guardando a droga pois foi ameaçado de morte (fl. 236/237).

As testemunhas de defesa José Cláudio da Silva Júnior, Aparecida de Fátima Palma e Maria Aparecida de Souza, ouvidas em juízo, nada souberam esclarecer sobre os fatos, limitando-se em tecerem comentários sobre o réu (fls. 236/237).

Logo, tais depoimentos não bastam para comprovar a alegada coação moral irresistível, como se verá logo abaixo, lembrando que o ônus da prova do fato narrado na denúncia, em regra, é da acusação, no entanto, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, nos termos do artigo 156, caput, do Código de Processo Penal. No caso, a coação moral irresistível foi alegação da defesa.

Por outro lado, no que se refere aos entorpecentes, a perícia apontou que consistem realmente em "maconha" e "cocaína" (exames químico-toxicológicos de fls. 105/107 e 113/117).

De outra parte, a grande quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, ou seja, 47,2g de cocaína e 830,99g de maconha; as circunstâncias da abordagem do réu (denúncia de que o réu estaria comercializando drogas em sua residência); a apreensão de celulares e dinheiro, e a confissão do réu em juízo, estão a caracterizar a traficância.

Nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo e guarde a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. No caso, o réu foi denunciado trazer consigo e guardar os entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a venda a terceiros. Neste ponto, irrelevante a alegação da defesa de que o réu estaria guardando a droga para terceira pessoa. O tipo penal do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 é chamado de tipo misto alternativo, possuindo vários núcleos, dentre eles trazer consigo e guardar, condutas essas efetivamente praticadas pelo acusado, mas que caracterizam crime único.

Quanto ao dinheiro e a um dos celulares apreendidos, o acusado não fez qualquer prova sobre a sua procedência lícita, e não arrolou seu irmão, para confirmar que o celular lhe pertencia, nem juntou documentos que comprove ser o dinheiro ser proveniente de pensão alimentícia de sua companheira, razão pela qual, diante da prova acima analisada, não há como se deixar de reconhecer que são produto do tráfico de entorpecentes.

Assim, além da robusta prova acima analisada, há indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no

próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios. Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia, o acusado trazia consigo e guardava 830,99 gramas (oitocentos e trinta gramas e noventa e nove centigramas) de maconha e 47,20 gramas (quarenta e sete gramas e vinte centigramas) de crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de entrega a consumo de terceiros.

A conduta do réu encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. Neste ponto, não prospera, como já acima exposto, a alegação de que o réu teria agido mediante coação moral irresistível. Como se sabe, essa figura somente está presente quando a coação não poderia ser vencida ou superada pelo agente no caso concreto, o que não é caso dos autos. Frise-se, o réu não arrolou testemunha que comprovasse diretamente tal fato, tratando-se de alegação vazia, sem qualquer fundamento, no intuito de afastar sua responsabilidade penal. Por consequência, não há como se admitir a alegação defensiva de que o réu, quando guardava a droga em sua casa, tinha sua vontade comprometida.

Em outros termos, não há prova de que o réu estaria guardando a expressiva quantidade de maconha e crack, por estar sendo ameaçado de morte. Lembre-se de que a única testemunha de defesa ouvida na instrução que mencionou tal fato foi sua companheira Lorryne, mas não deu maiores detalhes.

Ainda com relação à coação moral irresistível, anoto que o réu, em nenhum momento, relatou tal fato aos policiais militares que o prenderam, assim como na delegacia, nada mencionou sobre estar sendo ameaçado.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, exclua a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade. Neste ponto, embora o acusado, em seu interrogatório, tenha alegado que é usuário de drogas, tais alegações não restaram comprovadas. Pressuposto disso, é que o agente assume que a droga a pertencia e que fosse para seu uso, mas não foi que aconteceu nos autos, já que na delegacia, o réu negou a propriedade da droga e em juízo, disse que parte dela ele guardava para terceiro traficante. Ademais, em seu interrogatório, o réu mostrou-se lúcido, razão pela qual foi indeferido o pedido de exame toxicológico.

Ressalto que, mesmo que se demonstrasse que o réu fosse usuário de drogas, isso, por si só, não lhe impediria de exercer a traficância. Muito pelo contrário, há grande afinidade entre uma e outra condutas. Se o réu é viciado há um bom tempo, isso facilita o ingresso no submundo do crime, principalmente no mercado de substâncias tóxicas.

Diante desse quadro, a condição de ser o agente usuário de drogas não exclui a possibilidade de ser condenado como traficante, porque são situações que não se excluem, ainda mais no caso, em que o próprio réu assumiu que a droga era de terceira pessoa e ele estava somente guardando-a, em troca de pagamento em dinheiro.

Reconheço, pois, a ocorrência do delito, e passo a aplicar a pena.

O acusado ostenta mau antecedente (fls. 272/273 - processo nº 0007471-16.2012.8.26.0077), razão pela qual uma das circunstâncias do art. 59 do Código Penal não lhe é favorável, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Afora isso, nesta fase da aplicação da pena, deve ser levado em conta que a introdução da considerável quantidade de droga no mercado (nada menos do que 830,99 gramas de maconha e 47,2 gramas de crack), se fosse alcançada, traria efeitos altamente lesivos à sociedade. Evidente, assim, a necessidade de um maior rigor na fixação da pena-base, em patamar acima do mínimo legal, lembrando que seria absolutamente desprovido de razoabilidade apená-lo com a sanção base mínima, tratando-o igualmente, por exemplo, a quem fosse preso traficando algumas gramas daqueles entorpecentes.

Essa é a posição de nossos Tribunais:

“Na avaliação das circunstâncias legais para a fixação da pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade da droga. O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde pública, correlato ao indicador das consequências do crime; a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa e voltada para a prática criminosa” (STJ, HC 13.231-MS, 5ª T., j. 22.08.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 09.10.2000 – RT 786/599).

“Nos casos de tráfico de entorpecente, a fixação da pena obedecerá aos critérios do art. 59 do CP entre eles os motivos, as circunstância e consequências do crime, razão pela qual se admite a fixação de pena-base acima do mínimo legal, se houve apreensão de grande quantidade de droga” (STJ, HC 11.235-SP, 5ª T., j. 16.03.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 17.04.2000, RT 783/594).

“Admissível, em tema de comércio clandestino de entorpecente, é a maior severidade na repressão penal em face da natureza mais nociva ou da maior quantidade de substância tóxica apreendida” (TACRIM-SP-AC-Rel. Geraldo Pinheiro – JUTACRIM 44/293).

“A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS – AC – 687055624 – Rel. Alberto de Moraes Lacerda – RJTJRS 130/154).

PENA – Agravantes – Tráfico de entorpecentes – Associação – Hipótese em que, se a Justiça Pública houvesse apelado, caberia modificação no decreto condenatório, pois a grande quantidade de entorpecente apreendida justificaria plenamente a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, além de que o “modus operandi” do casal criminoso, demonstra organização que merecia maior rigor punitivo; todavia, como não é possível “reformatio in pejus”, a pena cominada na r. sentença deve prevalecer – Preliminar rejeitada, recurso parcialmente provido. (Apelação Criminal n. 1.044.309-3/5 – São Paulo – 6ª Câmara Criminal – Relator: Marco Antonio – 23.8.2007 – V.U. – Voto n. 6.277)

Portanto, levando em conta o dado elencado, nos aspectos acima relatados (mau antecedente e quantidade da droga), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1/3 (um terço), resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a circunstância agravante da reincidência (fls. 270/271 – processo nº 000266-31.2017.8.26.0603), razão pela qual elevo a pena em mais 1/6 (um sexto), resultando em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes a ser consideradas.

Não é caso de reconhecimento da atenuante da confissão, porque o réu alegou coação moral irresistível, procurando eximir-se de sua responsabilidade penal, lembrando que o entendimento deste Juízo é no sentido de que a confissão espontânea a que alude o artigo 65 do Código Penal, como circunstância determinante de alguma redução de pena, é aquela sem ressalvas, sem desculpas para o gesto criminoso, a qual não restou configurada no caso.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas. Não é caso de incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porque o réu é reincidente e ostenta mau antecedente, o que afasta o benefício.

Ademais, ainda que o réu fosse primário, a quantidade expressiva de entorpecente, inversamente ao princípio da insignificância, poderia causar consequências

gravíssimas a um número imenso de pessoas, bem como denota periculosidade acentuada por parte do acusado, já que realizava o tráfico em escala considerável, o que deve ser diferenciado do pequeno traficante, sob pena de violação do primado da igualdade, de modo que é forçoso reconhecer que se dedicava a atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida, o que só vem confirmar a não incidência da causa de diminuição supracitada.

Torno definitiva a pena em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Diante da gravidade da conduta, mesmo levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12 (art. 2º, que acrescentou o § 2º ao art. 387 do CPP), a pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, obrigatoriamente, pois se trata de crime equiparado a hediondo, conforme estatuído no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.

Ademais, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária do acusado, isto é, se não registra outras condenações ou prisões processuais, nem quanto ao seu comportamento e conduta no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua de informações concretas.

O acusado deverá continuar a responder preso por este processo, pois assim permaneceu durante a instrução e ainda estão presentes os requisitos da custódia cautelar, como se verá doravante.

Fica fixado cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR TONI RICO SILVA JUNIOR, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no menor valor (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consigno que o acusado ficou preso cautelarmente desde 13/02/2022 até a presente data, período sobre o qual fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restante da pena, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.736/12.

Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se consignar a condenação total constante do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detração penal).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender incabível tal providência.

Não obstante o julgamento do Habeas Corpus n. 97.256, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu por inconstitucional a vedação à substituição por penas restritivas de direitos para o crime de tráfico, por afronta ao princípio da individualização da pena, até então não se trata de decisão proferida com efeito erga omnes.

Foi editada a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, que, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, suspendeu a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que vedava de forma abstrata (sem análise do caso concreto) a conversão em penas restritivas de direito, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo em decisão no Habeas Corpus já mencionado acima.

Com a mencionada Resolução, não se pode mais afirmar que o efeito do julgamento daquele habeas corpus não é para todos. Entretanto, a intenção do Supremo Tribunal Federal, ao decidir desta forma, e o Senado Federal, ao editar a resolução, foi somente deixar à prudente análise do magistrado do caso concreto se o réu tem ou não direito a ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e não que essa substituição seja admitida em qualquer caso de tráfico de drogas, indistintamente. Pensar assim seria um contrassenso.

Confira, neste sentido, decisão proferida em Apelação Criminal que analisou

sentença proferida por este juízo:

"... Inviável, nesse passo, a pretendida substituição carcerária por restritivas de direito, porque, embora o teor da recente Resolução nº. 5/2012 do Senado Federal, fundada na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Habeas Corpus, nº. 97.256/RS – mencionado nas razões recursais –, em controle difuso de constitucionalidade, in casu, permanece impossível, data vênua, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, ou mesmo a concessão de sursis, pois o crime de tráfico de entorpecentes revela a gravidade peculiar que desestabiliza a vida em sociedade e fere de morte a saúde pública, pois enquanto fomenta, simultânea e irremediavelmente – até as pedras estão cansadas de saber –, a violência, a destruição de lares e das famílias e a prática de n crimes, sobretudo para o fim de viabilizá-lo, tanto assim que, por força de norma constitucional, é assemelhado aos delitos hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a suspensão condicional da pena, de modo que não se consegue compreender ou avaliar, por mais que se esforce, qual seria a pena substitutiva ou as condições do sursis adequadas ao traficante, emergindo sintomático que – até o momento – jurista sério algum tenha ousado sugeri-las..." (TJ-SP, Apelação Criminal nº 0009435-15.2010.8.26.0077, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Juvenal Duarte, j. 19.04.2012).

Ainda no mesmo sentido, confira julgamento proferido em processo que tramitou por essa comarca de Birigui:

"Também não faz jus a apelante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados a tráfico de drogas é incompatível com a gravidade e as circunstâncias em que o crime é cometido, não havendo qualquer tipo de violação ao princípio da individualização da pena.

Este entendimento deve prevalecer, notadamente ao se considerar a vedação expressa trazida pelo artigo 44 da Lei de Drogas.

Com efeito, o benefício consistente na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem por objetivo primordial o de possibilitar a ressocialização de indivíduos de baixa periculosidade, que praticaram delitos de pequeno grau de lesividade social.

Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de pequeno, médio ou grande porte, não tem o perfil de iniciar o cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor, as quais virão a repercutir a toda a coletividade. Ressalta-se que uma das exigências previstas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a de que os motivos e as circunstâncias indiquem como suficiente tal medida, para a repressão do agente da conduta delituosa.

Conforme já fundamentado, tal benefício não se coaduna com as graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causa, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental, mas também ao corpo social (desestrutura familiar, estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).

Muito embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do "Habeas Corpus" nº 97256/RS, tenha expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06, é de se ressaltar que tal decisão não possui o erga omnis.

E mesmo a resolução nº 5 do Senado Federal, de 15 de fevereiro de 2012, que suspendeu a eficácia da referida expressão, não acarreta direito subjetivo do agente que praticou o grave delito do tráfico de entorpecentes a tal conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Frise-se, ainda, que o artigo 44 da Lei de Drogas mantém tal vedação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput. Considerando que o § 4º é tão somente uma causa de diminuição do delito previsto no caput – e não um crime autônomo –, é possível concluir que a vedação a ele também se aplica. Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci que “(...) o fato de haver sido prevista uma causa de diminuição de pena para o traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações criminosas, não afasta a tipificação da sua conduta como incursas no artigo 33, caput e § 1º, que são consideradas similares a infrações penais hediondas, como se pode observar pelas proibições enumeradas no artigo 44 da Lei 11343/06. Salienta-se, ademais, o cuidado legislativo em vedar a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, típica opção de política criminal para o tráfico ilícito de drogas. Não se pode criar uma nova infração penal, a partir da mera aplicação de causa de diminuição de pena. Por isso, o tráfico ilícito de drogas será sempre considerado equiparado a hediondo, ainda que comporte, por opção legislativa, pena mais branda, quando os requisitos do § 4º estiverem presentes” (in “Leis Penais e Processuais Penais Comentadas”, 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p.372). Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau” (Apelação Criminal nº 0002364-20.2014.8.26.0077. Rel. Toloza Neto).

Não bastassem todos os argumentos expostos nos votos supracitados, no caso concreto, a substituição não é possível porque o acusado ostenta mau antecedente, é reincidente e a pena aplicada é superior a quatro anos. Ademais, o réu é reincidente específico, o que afasta até mesmo a aplicação do § 3º do artigo 44 do Código Penal. Afora isso, o réu estava guardando considerável quantidade de entorpecente para entrega a consumo de terceiros, o que demonstra que o benefício não seria recomendável, nem suficiente para a prevenção e repressão do crime praticado.

O acusado deverá continuar a responder preso a este processo, eis que sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva às fls. 64/67, a cujos fundamentos me reporto, como razão de decidir, bem como aqueles expostos nas decisões de fls. 171/172 e 224/225, que indeferiram os pedidos de revogação da prisão preventiva e prisão domiciliar.

Por fim, anote-se que o réu guardava grande quantidade de drogas, o que traria efeitos altamente lesivos à sociedade e só vem confirmar a necessidade de manutenção de sua prisão cautelar, para garantia da ordem pública, lembrando que o acusado é reincidente em crime doloso.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, com fundamento nos artigos 59 da Lei nº 11.343/06, c.c. o § 4º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, acrescentado pela Lei nº 11.464/07.

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, após 85 (oitenta e cinco) dias contados da publicação da sentença, tornem os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção ou não da decisão que manteve a prisão preventiva, mantendo-se os autos na fila “acompanhamento de prisão preventiva”.

A incineração da droga já foi determinada e realizada às fls. 175/181, nada mais havendo a ser decidido a respeito.

Como o acusado não provou a procedência lícita do dinheiro apreendido (fls. 111/112 - R\$ 320,00), indefiro o pedido de restituição, pois não há como se deixar de reconhecer que é produto do tráfico de entorpecente praticado pelo acusado. Logo, com fundamento nos artigos 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, e 63 da Lei nº. 11.343/06, decreto o perdimento do dinheiro apreendido às fls. 111/112 e depositado nos autos à fl. 104.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o “Senad” quanto ao perdimento supra determinado, instruindo o ofício com cópias do auto de exibição e apreensão, da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Quanto à embalagem de alumínio apreendida (fls. 111/112), embora sejam instrumentos

do tráfico de drogas, o certo é que, diante da natureza do objeto, entendo não ser caso de perda em favor do Senad, mas sim destruição imediata, a qual fica desde já determinada, expedindo-se o necessário e comunicando-se a Sala de Armas e Objetos Apreendidos.

Por fim, em relação aos celulares apreendidos às fls. 111/112, indefiro o pedido de restituição formulada pela defesa, e diante da natureza dos objetos, (e por serem, os celulares, instrumentos para a prática do tráfico de drogas), entendo não ser caso de perda para o SENAD, mas sim destruição, a qual fica desde já determinada, mas que deverá ser cumprida somente após o trânsito em julgado da presente.

Oficie-se também à Delegacia de Polícia de origem, informando sobre o perdimento do dinheiro (R\$ 320,00) e sobre a destruição dos objetos, instruindo-se o ofício com as cópias acima mencionadas.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas, na forma da lei.

P. R. I.

Birigui, 05 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA